

1500415-06.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500415-06.2021.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 14 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500415-06.2021.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS GUILHERME RUPEO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUÍS GUILHERME RUPEO por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de março de 2021, por volta das 22h30, na Rua Francisco Gomes Pato, 151, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, LUÍS GUILHERME RUPEO, qualificado à fl. 05, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) porção de maconha com peso líquido de 14,46 - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo pericial de fls. 14/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que o imputado resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro não identificado e repassadas ao consumo de terceiros.

Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando

avistaram o denunciado defronte a sua residência juntamente com outras duas pessoas, sendo que todos esboçaram reação suspeita. Diante disso, os policiais começaram a observá-los, oportunidade em que o increpado lançou sobre o telhado do imóvel um objeto, o qual rolou e acabou caindo na calçada ao lado dos milicianos.

Nesse contexto, os policiais constataram que o objeto se tratava de 01 (uma) porção média de maconha e outras 08 (oito) porções menores da mesma substância. Em revista pessoal, localizaram a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em poder do denunciado e mais R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) dentro do imóvel, além de um plástico filme idêntico ao utilizado para embalar as drogas.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento, a quantidade de dinheiro encontrada, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega a consumo de terceiros".

A denúncia foi recebida em 16/11/2021 Fls. 110/112

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela nulidade probatória, desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas e, subsidiariamente, a absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não há nulidade na busca domiciliar, posto que houve consentimento para o acesso à residência.

No julgamento do HC 598.051 - SP, a Sexta Turma do STJ definiu que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

O depoimento do policial militar deve prevalecer, pois não há elementos concretos que afastam a presunção de veracidade. A avó do réu franqueou o acesso. Ademais, nada de ilícito foi encontrado no interior da residência.

Portanto, REJEITO esta preliminar.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de fls. 07/09; auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de apreensão de fls. 10/11; laudo pericial de fls. 14/16; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Élcio José Bertholdo, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento, em razão de informações de que o réu estava praticando tráfico de drogas no local. Na área da residência tinham dois indivíduos. Quando passaram com a viatura, o réu jogou um objeto em cima do telhado, rolou e caiu perto da viatura. Consistia em um pedaço de maconha enrolado em plástico transparente. Abordaram o réu e encontraram R\$30,00. Em sua casa foi localizado R\$230,00. Não se recorda se na casa tinha embalagem para embalar droga. Existiam várias denúncias de que o réu estava praticando tráfico de drogas no local. A avó do réu autorizou a entrada na residência.

Interrogado judicialmente, o réu confessou que a droga era de sua propriedade, mas negou o tráfico de drogas. Disse que a maconha era para seu consumo pessoal.

Do percuciente do quadro probatório, infere-se que a conduta do acusado melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo prova segura

e concludente da finalidade da traficância, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia.

A materialidade do delito restou comprovada, mas constatada a ausência de provas quanto a versão acusatória, que se contrapõe com a firme alegação da processada no sentido de que a droga servia ao seu consumo, não há que se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta um mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reprisa-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é geralmente perpetrado na clandestinidade, devendo a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de caderno probatório substancioso, melhor é adotar o princípio do in dubio pro reo, preservando-se as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada (23g de maconha), a pouca quantidade dinheiro em espécie encontrada com o réu (R\$ 30,00), e a falta de variedade, autoriza crer que a versão exculpatória da defesa é verossímil, consubstanciada na tese de que a droga seria para consumo próprio.

Por certo, a linha que diferencia as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 é tênue. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015).

Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que a réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder destinavam-se ao comércio ilícito.

Vejamos o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

"As cinco condutas previstas no art. 28 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do art. 33 (antigo art. 12 da Lei

6.368/76). Entretanto, neste último caso, cuida-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, gerando pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa elevada, enquanto o outro não constitui delito equiparado a hediondo, sem a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, somente porque a finalidade do agente é o consumo pessoal. Em face disso, muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Por outro lado, inúmeros usuários acabam, injustamente, autuados com base no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76), quando merecem a desclassificação para o art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade da droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante (art. 33). No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário (art. 28).

Não havendo provas de efetiva realização de atos que o réu tinha a intenção de comercializar a substância entorpecente, não há que se falar em crime de tráfico de drogas. Assim, devida, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso.

Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 15006112120188260559 SP 1500611-21.2018.8.26.0559, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APL: 00425368720148260114 SP 0042536-87.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2017; APR: 15117210620198260228 SP 1511721-06.2019.8.26.0228, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APR: 15007932920198260411 SP 1500793-29.2019.8.26.0411, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021.

Como se trata de delito de menor potencial ofensivo (art. 60, caput, da Lei 9.099/98) e o réu não possui antecedentes, é medida de rigor a proposição de transação penal ou de suspensão condicional do processo, pois são benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e maus antecedentes, cuja proposta cabe ao Ministério Público.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e CONDENAR o réu como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e, em consequência, reconhecer a aplicabilidade de medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/98, mediante proposta do Ministério Público oportunamente.

Com o trânsito em julgado, abra-se vista ao Ministério Público para que seja ofertada a proposta.

Em decorrência, determino a restituição do valor apreendido em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 10/11. CUMPRA-SE.

Oficie-se ao IIRGD.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 14 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA